



G7 Jurídico

Analistas
Direito Processual Penal – Nestor Tavora
Aula 04

MATERIAL DO PROFESSOR

3.2.2- Princípio da INDISPONIBILIDADE

I- Conceito: o MP não poderá desistir da demanda deflagrada, devendo promover o impulsionamento como desdobramento de um dever funcional (art. 42, CPP).

II- Postura do MP:

a) O MP poderá requerer a absolvição do réu, o que não significa desistência.

Conclusão: de acordo com o art. 385 do CPP, o juiz poderá divergir, condenando o imputado.

b) Os recursos criminais são **ESSENCIALMENTE VOLUNTÁRIOS**. Todavia, se o MP recorrer, **NÃO PODERÁ DESISTIR**, já que o recurso é um **DESDOBRAMENTO DO DIREITO DE AÇÃO** (art. 576, CPP).

III- Princípio da INDISPONIBILIDADE MITIGADA- ela é caracterizada dentro da justiça penal negociada, por meio dos seguintes institutos:

a) Suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9099/95);

b) Colaboração premiada, já que o colaborador pode ser beneficiado com **PERDÃO JUDICIAL** (art. 4º, Lei 12.850/013);

c) Para o STF, caberá ANPP para processos em curso quando do advento do Pacote Anticrime, desde que a defesa se manifeste na primeira oportunidade, antes do trânsito em julgado da demanda.

3.2.3- Princípio da DIVISIBILIDADE

I- Conceito: para os Tribunais Superiores, a ação pública é divisível por admitir desmembramento e complementação incidental via aditamento.

II- Posição doutrinária prevalente- para a doutrina majoritária (Afrânio Silva Jardim), a indivisibilidade rege a ação pública, como desdobramento subjetivo do princípio da obrigatoriedade.

3.2.4- Princípio da INTRANSCENDÊNCIA/ PESSOALIDADE

I- Conceito: a ação penal não pode ultrapassar a figura do imputado.

3.2.5- Princípio da AUTORITARIEDADE

I- Conceito: a ação de iniciativa pública será exercida por autoridade pública.

3.2.6- Princípio da OFICIALIDADE

I- Conceito: ação de iniciativa pública será exercida por um órgão oficial do Estado.

3.2.7- Princípio da OFICIOSIDADE

I- Conceito: de regra, a ação pública será proposta EX OFFICIO.

3.3- Modalidades (classificação):

3.3.1- Ação pública INCONDICIONADA

I- Conceito: é aquela titularizada pelo MP, onde a atividade persecutória ocorrerá ex officio, independente da manifestação de vontade da vítima ou de terceiros.

Obs.1. Ela é a REGRA GERAL, em conformidade com o art. 100, caput, CP.

Conclusão: quando o tipo penal é omissivo, presumiremos que o crime é de ação pública INCONDICIONADA.

Obs.2. Nos crimes de ação pública INCONDICIONADA, o IP deve ser iniciado ex officio (art. 5º, I, CPP).

3.3.2- Ação pública CONDICIONADA

I- Conceito: é aquela titularizada pelo MP, mas que dependerá de uma prévia manifestação de vontade do legítimo interessado.

Obs.1. Almejamos evitar o “strepitus judicii” (escândalo do processo).

Obs.2. Para o condicionamento da ação pública, é necessário expressa previsão na lei (art. 100, § 1º, CP).

Obs.3. O crime de ESTELIONADO passou a ser, de regra, crime de ação pública CONDICIONADA, salvo diante de uma especial condição da vítima (§ 5º, art. 171, CP).

Obs.4. A injúria racial atualmente é tratada como RACISMO, sendo crime de ação pública INCONDICIONADA (art. 2º-A, Lei 7716/89).

Obs.5. A ameaça de gênero é considerada crime de ação pública INCONDICIONADA (§ 2º, art. 147, CP).

II- Institutos CONDICIONANTES:

a) Representação:

a.1) Conceito: é o PEDIDO e ao mesmo tempo a AUTORIZAÇÃO que condiciona o início da persecução penal.

Conclusão: sem ela não haverá ação, IP ou lavratura de flagrante.

a.2) Natureza jurídica: ela é uma CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE, leia-se, uma condição para providências persecutórias.

Conclusão: para Denilson Feitoza, ela é uma condição especial da ação.

a.3) Legitimidade:

a.3.1) Destinatários:

- delegado (art. 5º, § 4º, CPP);

- MP

Obs. Postura: requisitar a instauração de IP (art. 5º, II, CPP); instaurar PIC; promover o arquivamento da peça informativa; oferecer denúncia no prazo de 15 dias da provocação (art. 46, CPP).

- Juiz

Obs. Postura: requisitar a instauração de IP; abrir vistas ao MP.

a.3.2) Legitimidade ATIVA- é da vítima ou do seu representante legal.

Obs.1. A emancipação não tem reflexos penais. Logo, ao emancipado será nomeado CURADOR ESPECIAL.

Obs.2. Morte ou ausência da vítima – diante da morte ou da ausência, o direito de representar se transfere aos seguintes sujeitos:

Cônjuge/ companheiro(a);

Ascendentes;

Descendentes;

Irmãos.

Conclusão1. O rol é preferencial e taxativo (§ 1º, art. 24, CPP).

Conclusão2. De acordo com o STJ, o companheiro (a) é alocado ao lado do cônjuge.

a.4) Prazo- 6 meses contados do CONHECIMENTO DA AUTORIA DA INFRAÇÃO (art. 38, CPP).

Obs.1. O prazo é DECADENCIAL, o que significa dizer que é um prazo FATAL, não tolerando suspensão, interrupção ou prorrogação.

Obs.2. O dia do conhecimento da autoria já entra na contagem do prazo.

Obs.3. A perda do prazo provoca a extinção da punibilidade (art. 107, IV, CP).

a.5) Forma- de acordo com o STF e o STJ, a forma é LIVRE, já que o legitimidade poderá representar oralmente ou por escrito a qualquer dos destinatários.

a.6) Retratação:

a.6.1) Regra GERAL- a vítima poderá se retratar da representação até antes do OFERECIMENTO DA DENÚNCIA (art. 25, CPP).

Obs.1. Se a vítima se retratou, ela poderá se arrepender e reapresentar a representação, desde que DENTRO DO PRAZO, que está contando do conhecimento da autoria (posição MAJORITÁRIA).

Conclusão: “Cabe retratação da retratação da representação” (V).

Conclusão2. A doutrina minoritária entende que a retratação caracteriza uma renúncia, provocando a extinção da punibilidade (Tourinho Filho).

a.6.2) Violência doméstica

Obs.1. Existem crimes de ação pública CONDICIONADA na violência doméstica, a exemplo da perseguição (art. 147-A, § 3º, CP).

Obs.2. Se a mulher representou, poderá se arrepender (a lei fala em renunciar), retirando a representação em audiência específica, na presença do juiz, ouvindo-se o MP (art. 16, Lei 11.340/06).

ADVERTÊNCIA: a doutrina majoritária entende que esta renúncia é uma mera retratação.

Obs.3. O arrependimento pode ser exercido até antes do RECEBIMENTO da denúncia.

Obs.4. A posição consolidada é que a audiência para retratação só será marcada se a vítima indicar que deseja se retratar, não sendo um ato automático.

Obs.5. A ameaça de gênero passou a ser crime de ação pública INCONDICIONADA (§§ 1º e 2º, art. 147, CP).

Obs.6. A lesão corporal, mesmo que LEVE, mas no contexto de violência doméstica, é crime de ação pública INCONDICIONADA, afinal, não aplicaremos o art. 88 da Lei 9099/95, por força do art. 41 da Lei Maria da Penha (Súmula 542, STJ).

a.7) Eficácia objetiva- para a doutrina majoritária, se a vítima apontou parte dos sujeitos ao representar, o MP poderá denunciar outras pessoas, afinal, a representação é uma autorização pra providencias quanto ao delito indicado.

Obs. Para Luiz Flávio Gomes, deve o MP provocar o ofendido a complementar a representação. Não o fazendo, a vítima estará renunciado, extinguindo a punibilidade em benefício de todos (posição minoritária).

a.8) Não vinculação- a representação é uma autorização e um pedido. Se o MP entender que não há delito, promoverá o arquivamento da peça de informação.

b) Requisição do Ministro da Justiça

b.1) Conceito: é uma autorização com caracter polícitico e que condiciona o início da persecução penal.

Conclusão: sem ela inexistente ação, inquérito ou lavratura de flagrante.

b.2) Natureza jurídica- ela é enquadrada como condição de procedibilidade, sendo, em última análise, uma condição especial para o exercício da ação penal.

b.3) Legitimidade:

b.3.1) Destinatário: o PG do MP.

b.3.2) Ativa- é do Ministro da Justiça.

b.4) Prazo- INEXISTE prazo decadencial para o exercício da REQUISIÇÃO.

Conclusão: logo, o Ministro da Justiça poderá requisitar a qualquer tempo, desde que não ocorra a extinção da punibilidade pela prescrição ou por qualquer outra causa.

b.5) Retratação

b.5.1) 1º posição: para Guilherme Nucci e Luiz Flávio Gomes, o ato comporta retratação até antes do OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, em analogia ao que ocorre com a representação da vítima (art. 25, CPP).

b.5.2) 2º posição: para Tourinho Filho, o ato é IRRETRATÁVEL, não só por ausência de previsão legal (fundamento jurídico), como também para não comprometer a imagem do país (fundamento político).

ADVERTÊNCIA: os Tribunais Superiores NUNCA julgaram a matéria.

b.6) Eficácia OBJETIVA- prevalece o entendimento de que o MP poderá denunciar pessoas não apontadas na requisição, sendo ela uma autorização para providência por determinado fato.

b.7) (Não) vinculação- diante da INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL do MP, não há vinculação. Logo, pode ocorrer o arquivamento da peça de informação, bem como alteração dos artigos de lei sugeridos pelo Ministro da Justiça.

4- Ação penal de INICIATIVA privada

4.1- Conceito: é aquela exercida pela vítima ou por seu representante legal na condição de SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, já que ela atua em nome próprio pleiteando a punição, que será exercida pelo Estado.

Obs.1. Crítica- Para Aury Lopes Jr, não podemos confundir o exercício da ação com o exercício da punição, sendo inadequado falarmos em substituição processual.

Obs.2. Enquadramento TERMINOLÓGICO:

a) Vítima- como titular da ação privada, é chamada de QUERELANTE.

b) Réu- no polo passivo da ação privada, é chamado de QUERELADO.

c) Petição inicial- é chamada de QUEIXA-CRIME, sendo que os seus requisitos estão no art. 41 do CPP.

4.2- Princípios:

4.2.1- Princípio da OPORTUNIDADE

I- Conceito: a vítima só exercerá a ação privada se lhe for conveniente.

II- Institutos correlatos:

a) Decadência

a.1) Conceito: é a perda da possibilidade de ingressar com a ação privada em razão do decurso do tempo, qual seja, em regra 6 meses contados do CONHECIMENTO DA AUTORIA DA INFRAÇÃO (art. 38, CPP).

Obs. Como o prazo é fatal, não se interrompe, não se suspende ou se prorroga, sendo contado de acordo com o art. 10 do CP.

ADVERTÊNCIA: a pendência de conclusão do IP não interfere no prazo.

a.2) Consequência- ela provoca a extinção da punibilidade (art. 107, IV, CP).

b) Renúncia

b.1) Conceito: ela ocorre pela declaração expressa da vítima de que não pretende ingressar com a ação privada (art. 50, CPP), bem como pela prática de ato incompatível com esta vontade (art. 57, CPP).

Conclusão: a renúncia pode ocorrer de forma expressa ou tácita, comportando todo meio de prova.

b.2) Consequência: ela provoca a extinção da punibilidade (art. 107, V, CP).

b.3) Irretratabilidade- inexistindo vício na formação de vontade, o ato é IRRETRATÁVEL.

b.4) Juizado especial criminal- ocorrendo a composição civil dos danos em crime de ação privada ou de ação pública condicionada, teremos a RENÚNCIA, provocando a extinção da punibilidade (art. 74, Lei 9099/95)

4.2.2- Princípio da DISPONIBILIDADE

I- Conceito: a vítima poderá desistir da demanda proposta, quando desejar.

II- Institutos correlatos:

II.1- Perdão

a) Conceito: ele ocorre quando a vítima declara expressamente que não pretende continuar com a demanda em curso, bem como quando ela pratica ato incompatível com esta vontade (art. 58, CPP).

Conclusão: o perdão pode ser OFERTADO tanto de forma expressa quanto de forma tácita.

b) Bilateralidade: para que o perdão surta o efeito pretendido, qual seja, a extinção da punibilidade, é necessário que o réu o aceite, o que pode ocorrer de forma expressa ou tácita (art. 59, CPP).

c) Procurador- tanto a oferta quando a aceitação do perdão podem ocorrer por meio de procurador, exigindo-se poderes especiais (art. 55, CPP).

d) Procedimento- se a vítima declarar nos autos o perdão, o réu terá 3 dias para dizer se o aceita (art. 58, CPP). A omissão faz presumir a aceitação (aceitação tácita)

e) Distinção do perdão JUDICIAL- é um ato UNILATERAL do juiz, em situações expressamente autorizadas por lei, ocasionando a extinção da punibilidade (art. 107, IX, CP).

f) Momento- o perdão ocorre na fase processual, inclusive em grau de recurso.

Obs. Ele pode ocorrer dentro ou fora dos autos.

II.2- Perempção (descaso)

a) Conceito: é a sanção judicialmente imposta pelo descaso da vítima na condução da ação penal privada.

b) Hipóteses- elas estão no art. 60 do CPP, ocasionando a extinção da punibilidade (art. 107, IV, CP).

4.2.3- Princípio da INDIVISIBILIDADE